

1500081-04.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas.

De mais a mais, cumpre enfatizar que a Lei nº 13.964/2019 não afastou a hediondez do delito de tráfico de entorpecentes e não se trata de tipos penais distintos aqueles previstos no artigo 33, caput e § 4º, da Lei de Drogas. Acerca do tema:

"O tráfico de entorpecentes é o grande mal da sociedade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500081-04.2021.8.26.0594

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WALISSON RODRIGUES DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

WALISSON RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta de 12h06, na Rua Dr. Walter Belian, quadra 1, esquina com a Rua Gio Batta Fornetti, Jardim Vitória, nesta cidade e Comarca de Bauru, trazia consigo 5,48 g de entorpecente conhecido como crack, divididos em 27 porções, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia (fls. 1/2), por decisão de fl. 121 foi determinada a notificação do réu.

O réu foi notificado (fl. 125) e apresentou defesa prévia às fls. 126/129.

A decisão de fls. 138/141 recebeu a denúncia e deu início à fase de instrução, na

qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ao final, o réu foi interrogado (fl. 179-mídia).

Superada a fase de diligências, em alegações finais o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 183/185).

Em outro ângulo, a Defesa pugnou pela absolvição do réu sob o argumento de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, bem como aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, com fixação de regime inicial aberto e autorização para recorrer em liberdade (fls. 188/192).

É o relatório.
DECIDO.

Trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração do crime de tráfico de drogas.

O conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à procedência da denúncia.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 3, boletim de ocorrência de fls. 9/11, auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação provisória fls. 15/17, laudo toxicológico definitivo de fls. 109/111, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática criminosa. Disse que estava desempregado e, ao pedir trabalho a um indivíduo, este lhe propôs vender drogas. Esclareceu ter negado, todavia posteriormente acabou aceitando porque estava passando por necessidades. Falou que na data dos fatos era seu primeiro dia de mercancia e havia vendido poucas porções de entorpecente quando foi detido. Aduziu estar arrependido (fl. 179-mídia).

O policial militar João Henrique Coutinho de Souza relatou que efetuava patrulhamento pelo Jardim Vitória, local conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando observou o réu parado na esquina e notou que ele saiu correndo ao avistar a viatura. Contou que procedeu à abordagem, tendo sido localizados a quantia de R\$ 84,00 em notas diversas e dois pacotes plásticos contendo 27 pedras de crack. Mencionou que não conhecia o réu, o qual apenas afirmou que o estupefaciente se destinava ao consumo próprio. Acrescentou que não foram apreendidos objetos utilizados para uso da droga nem havia informações da prática criminosa pelo réu (fl. 179-mídia).

No mesmo sentido, o policial Luís Paulo dos Santos Quintanilla narrou que o réu estava em um conhecido ponto de tráfico de drogas do município e fugiu ao avisar a viatura, tendo sido perseguido e abordado, sendo encontrados com ele entorpecente e quantia em dinheiro. Asseverou que não conhecia o réu nem havia notícia de que ele praticava a mercancia, assim como não foram localizados objetos relacionados ao consumo de droga (fl. 179-mídia).

Ao que se vê, as provas carreadas aos autos, em especial a confissão do réu e os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem e da apreensão dos entorpecentes, dão respaldo ao decreto condenatório.

As circunstâncias evidenciam a prática do delito na modalidade “trazer consigo”, verbo nuclear trazido pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como se observa, o réu confessou o crime e a prática veio corroborada por todo o restante do conjunto probatório. Aliás, deve-se destacar que a confissão ostenta elevada carga probante a tranquilizar o espírito do julgador na formação do seu convencimento, ainda mais se confirmada pelas demais provas constantes nos autos, como no caso.

Outrossim, os policiais militares foram uníssonos e categóricos em afirmar como se deram os fatos, haja vista que, em patrulhamento por local conhecido pelo comércio de entorpecentes, avistaram o réu e, assim que percebeu a presença da viatura, tentou fugir do local, contudo foi detido. Em abordagem, encontraram em sua posse quantia em dinheiro e 27 porções de crack.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos policiais, os quais apresentaram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos militares revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos agentes, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos militares, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes.” (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

Ademais, precedente do Superior Tribunal de Justiça indica a relevância dos depoimentos de policiais:

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

(STJ. HC nº 267.025 – DF. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 02 de maio de 2013) (destaquei)

Ora, diante de toda prova produzida e com riqueza de detalhes de como se deram os fatos, não há se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Da análise do boletim de ocorrência de fls. 9/11, do auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, do laudo de constatação provisória de fls. 15/17 e do laudo toxicológico definitivo de fls. 109/111, é possível observar que foram apreendidas 27 pedras de crack (5,48 g), além da quantia de R\$ 84,00, a corroborar o exercício da traficância.

Não fosse pela prova oral produzida, já tão suficiente à condenação, a quantidade e a forma como os produtos foram encontrados, além da quantia em dinheiro encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Igualmente, para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas. A quantidade de entorpecente apreendido tem sido referencial na jurisprudência brasileira para caracterização do ilícito da mercancia. Claro que não basta essa única circunstância. Todo conjunto probatório leva à responsabilização do réu. Nesse sentido:

[...] 5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ [...] (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001686-11.2011.8.26.0400. Relator: Des. Airton Vieira. Data do julgamento: 10 de outubro de 2017)

Por todo o exposto, entendo que o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelo réu, do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria da pena.

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu não ostenta antecedentes criminais. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não lhes são desfavoráveis.

Destarte, por inexistir circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presentes as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea. Contudo, segundo a Súmula nº 231 do STJ, nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, de sorte que a sanção fica mantida da forma como anteriormente fixada.

Na terceira fase, há causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da primariedade do réu e da inexistência de antecedentes, bem como por não haver provas acerca de o réu se dedicar a atividades delituosas ou integrar organização criminosa. Dessa forma, a pena deverá ser reduzida em 2/3, resultando em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (sistema bifásico para a pena de multa).

Malgrado a quantidade de pena hipoteticamente autorizasse o início do cumprimento em regime aberto, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas.

De mais a mais, cumpre enfatizar que a Lei nº 13.964/2019 não afastou a hediondez do delito de tráfico de entorpecentes e não se trata de tipos penais distintos aqueles previstos no artigo 33, caput e § 4º, da Lei de Drogas. Acerca do tema:

"O tráfico de entorpecentes é o grande mal da sociedade contemporânea, que faz adoecer, de forma grave e muitas vezes irreversível, parte expressiva da população, instiga e propicia a prática de vários outros delitos, até mais graves, vitima a juventude e prejudica o seu desenvolvimento, desagrega as famílias e os relacionamentos e multiplica a indigência. Atuação como a do acusado coloca em perigo grande número de consumidores, e torna acessível droga de efeitos extremamente deletérios a pessoas que a ela não teriam alcance se encontrassem maior dificuldade em sua aquisição. Justificada a imposição, ao menos de início, do regime fechado, com vistas ao cumprimento das finalidades preventiva e retributiva da pena. [...] Incabível, ainda, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes hediondos ou equiparados, observando-se que o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas não define um tipo penal distinto do artigo 33, mas tão somente estabelece uma causa especial de redução de pena do mesmo crime de tráfico de entorpecentes. Neste ponto, ressalto que a recente Lei nº 13.964/2019 não alterou a natureza hedionda do crime do parágrafo 4º do artigo 33 da lei em comento. A única ressalva que fez para que tal delito não seja considerado como hediondo foi "para os fins deste artigo", referindo-se, exclusivamente, ao artigo 112 da LEP, que trata dos requisitos para a progressão de regime de pena (art. 4º, Lei nº 13.964/19). Ou seja, a nova lei limitou-se, em um parágrafo do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, a reduzir o prazo para progressão nos crimes de tráfico com redutor, mas não o excluiu da tipificação como equiparado a hediondo, já que, embora na mesma oportunidade e pelo mesmo diploma legal tenha feito alterações na Lei nº 8.072/90 (Lei que define os crimes hediondos e equiparados e disciplina seu tratamento diferenciado), não alterou o artigo 2º desta, que equipara o tráfico de entorpecente (independente de ser na forma simples, com aumento ou com redução de pena) aos hediondos. Urge salientar que o legislador, ao elaborar o vulgarmente denominado "Pacote Anticrime", promoveu alterações em inúmeras legislações, inclusive naquela que define o crime hediondo ou equiparado e, embora podendo definir nesta lei a exclusão do tráfico com o redutor do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não o fez. Optou, apenas e

tão somente e, de forma expressa, a tratar esta modalidade de tráfico de forma não equiparada a hediondo para fins do artigo 112 da LEP, ou seja, em relação ao prazo para progressão de regime. Há de se ressaltar ainda que a natureza e gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes, acima destacados, impedem a aplicação das penas alternativas. Além da frontal incompatibilidade com o regime prisional adequado (inicial fechado), não se reconhecem como preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 44, do Código Penal, na medida em que se evidencia insuficiente à prevenção e repressão do delito a substituição punitiva e suspensão da pena à vista do grau de reprovabilidade da conduta." (TJSP. 15ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 1500179-57.2019.8.26.0594. Relatora: Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti. Data do julgamento: 28 de novembro de 2019) (destaquei)

Outrossim, embora haja decisões das Cortes Superiores concedendo tais benesses, é certo que não possuem efeito erga omnes nem vinculante, de modo que a convicção dessa magistrada está preservada no tocante à análise do caso in concreto. Assim, o regime inicial será o fechado.

Por derradeiro, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista que a imposição da penalidade corporal ainda se faz necessária diante da gravidade do delito.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu WALISSON RODRIGUES DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época da infração para cada dia-multa, por violação ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal).

Comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido e depositado nos autos (fl. 137), decreto o perdimento da importância em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006. Transitada em julgado, providencie-se a transferência do numerário para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD (artigo 63, § 4º, da Lei de Tóxicos).

O réu respondeu ao processo em liberdade. Além disso, não se vislumbram os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de sorte que concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA